

1509831-27.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIA GONÇALVES CARDOSO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... as drogas, anotações indicativas de tráfico de drogas e insumos de tráfico; que a casa de trás estava aberta; que o réu permaneceu em silêncio; que a maior quantia das drogas estava na casa de trás e eram iguais às que estavam na casa dele; que reconhece o réu e que só havia o réu dentro da casa.

Já o Policial Rodrigo do Amaral Ruiz, também disse se recordar da ocorrência; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509831-27.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509831-27.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111535/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 24519594 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2111535 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBSON ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIA GONÇALVES CARDOSO

Vistos.

ROBSON ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, porque no dia 25 de abril de 2022, por volta de 16h30min, na Rua Engenheiro Jose Maria da Silva Velho, 156-A, Capão Redondo, nesta cidade e comarca, o agente supracitado mantinha sob sua guarda e depósito drogas, para a entrega ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e laudo de constatação provisória de fls. 26/31). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o agente supracitado possuía, no interior de sua residência, uma submetralhadora, da marca "Cobray", calibre 380, municiada com 04 (quatro) cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 86) e apresentou defesa prévia as fls.91.

Decisão de fls.45/50 converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Citado (fls.86), o réu apresentou resposta à acusação as fls.91.

A denúncia foi recebida em audiência de instrução e julgamento as fls.121/123.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. Após, procedeu-se ao interrogatório do réu.

Após, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, considerando a quantidade dos entorpecentes e pela não aplicação do redutor e regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição, apontando a fragilidade de provas, ou, subsidiariamente, pelo afastamento do crime autônomo do artigo 12 da Lei de Desarmamento e reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei 11343/06, pelo regime inicial aberto e direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03.

Passo a análise da prova oral produzida.

Em sede policial, o acusado narrou que “na data dos fatos, estava em sua residência, quando ouviu um barulho e percebeu que pessoas estavam entrando em sua residência e ao sair no quintal para ver o que estava acontecendo se deparou com os policiais pulando o muro. Em seguida os policiais informaram sobre uma denúncia de tráfico de drogas no local e então eles já foram entrando na residência sem pedir autorização; declara que os policiais encontraram uma arma de fogo, porém ela não está funcionando e não havia munições; o interrogado recebeu esta arma como parte do pagamento de uma motocicleta que vendeu para um indivíduo conhecido pelo nome de Bruninho. Informa que este indivíduo se mudou e não possui mais contato com ele e nem sabe onde ele pode ser localizado; declara que em sua residência havia apenas uma bucha de maconha que era para seu uso pessoal e nada mais, sendo que desconhece essas drogas apresentadas pelos policiais; informa que não autorizou e nem acompanhou a busca que os policiais fizeram na outra residência que fica nos fundos do terreno, sendo que o interrogado alugou esta casa para um indivíduo chamado Lucas, cujo apelido é “Cabeça”, porém o interrogado não chegou a fazer nenhum contrato de locação com ele e não sabe os demais dados de identificação deste indivíduo (fls.09).”

Em Juízo, o réu negou os fatos, disse que estava em casa na data dos fatos e que ouviu alguém mexendo no portão; que o policial já estava dentro de sua garagem informando-o que havia uma comunicação anônima; que informou aos policiais que havia duas casas no terreno e que havia alugado a casa de trás dia 10 passado; disse que o policial pediu para que ele abrisse o portão e franqueasse a entrada dos demais policiais, alegando que não precisava de mandado; informa que os policiais revistaram a outra casa, e alegaram que havia uma refinaria no local; que, após, os policiais revistaram a sua casa, e alegaram que encontraram drogas e uma arma; que não acompanhou a rotina dos locatários e que havia visto fogão, cama, botijão de gás dos locatários passando pelo terreno; que estava estudando e trabalhando, mas, quando ia para casa, encontrava-se com os locatários, com quem havia feito contrato verbal e combinado que pagariam R\$500,00 por 2 cômodos; que o apelido de um dos locatários era Cabeça, depois viu no Facebook que seu nome era Lucas e sua esposa se chamava Maria; que não é verdade que havia drogas na casa dele; que morava sozinho na casa; que a arma também não pertence a ele; que, depois do policial ter invadido seu terreno, os policiais não deixaram ele acompanhar a vistoria; que não viu droga ou arma; que também não franqueou a entrada de nenhum policial; que a família não estava lá; que viu a família locatária um dia antes da data dos fatos.

Ouvidos em sede policial, o Policial Militar Rodrigo do Amaral Ruiz disse que “foram acionados para verificarem denúncia anônima versando sobre movimentação de tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Engenheiro Jose Maria da Silva Velho, nº 156-A, Capão Redondo/SP. Ato contínuo se deslocaram até o referido local onde foram atendidos por ROBSON ALVES, o qual se identificou como

proprietário do imóvel e, após cientificado sobre a denúncia, permitiu que os policiais efetuassem uma vistoria na residência. Durante a vistoria na residência de ROBSON foi localizada no quarto, embaixo do guarda roupas, uma arma de fogo do tipo submetralhadora, aparentemente de fabricação caseira, com quatro projéteis calibre 380. No mesmo local também foram localizados 49 pinos com cocaína, 15 pedras de crack, 10 porções de maconha, 2 aparelhos celulares e a quantia de R\$45,00 em dinheiro. Ocorre que os policiais pertencem ao Batalhão do Canil da Tropa de Choque e estavam com o cão farejador e ele farejou a existência de entorpecentes na outra residência que ficava nos fundos do imóvel. O indiciado ROBSON disse que esta residência estaria alugada para um indivíduo que ele não soube fornecer os dados de identificação, porém, em vistoria nesta residência foi localizada uma mochila no quarto e dentro dela havia mais 85 pinos com cocaína, 188 porções de maconha, 50 porções de maconha do tipo Skank, 72 pedras de crack, R\$ 130,00 em dinheiro e papéis com anotações do tráfico de entorpecentes. Diante dos fatos, os entorpecentes e demais objetos foram recolhidos e apresentados nesta Delegacia (fls.15)."

Por sua vez, policial militar Jair Cardoso, também em fase processual, ratificou as alegações do companheiro de profissão (fls.16).

Ouvidos em juízo, os Policiais Militares confirmaram o teor das declarações anteriores. O Policial Jair Cardoso narrou que se recorda da ocorrência; que recebida a denúncia anônima, dirigiram-se até o local, uma residência, e chamaram pelo morador; que Robson saiu e franqueou a entrada; que foram localizados materiais ilícitos em sua residência; tanto na casa em que Robson mora (encontrada pouca substância - maconha, cocaína e crack e uma submetralhadora cromada municiada - calibre da submetralhadora é 380 embaixo do guarda-roupa), quanto na casa de trás, em que havia as demais drogas e as anotações indicativas de tráfico de droga (cerca de 40 pinos de cocaína e 15 pinos de crack; cerca de 180 invólucros de maconha, 50 invólucros de skank, 72 pedras de crack); que o réu alegou que a casa de trás estava alugada para outra pessoa; porém não havia nenhum indício de moradia pois não possuía móvel dentro da casa, apenas as drogas, anotações indicativas de tráfico de drogas e insumos de tráfico; que a casa de trás estava aberta; que o réu permaneceu em silêncio; que a maior quantia das drogas estava na casa de trás e eram iguais às que estavam na casa dele; que reconhece o réu e que só havia o réu dentro da casa.

Já o Policial Rodrigo do Amaral Ruiz, também disse se recordar da ocorrência; que o Robson estava na casa da frente franqueando a entrada dos policiais, tendo sido encontradas na casa dele pouca quantia de droga (maconha, cocaína, crack) e a arma; que, na casa de trás, que estava aberta, foi encontrada maior quantia de droga e anotações de tráfico e não havia qualquer indicativo de moradia; que as drogas de ambas as casas eram iguais; que o réu admitiu que a arma era dele, mas alegou que desconhecia as drogas; que o réu estava sozinho na casa; que desconhece se havia outro morador; que reconhece o réu.

Pois bem.

Após revisar minuciosamente a prova dos autos, verifico que não há como sustentar a condenação em provas válidas. Entendo que a apreensão das drogas na residência do acusado foi ilícita e, por esta razão, não pode servir à condenação, o que conduz à improcedência da imputação por ausência de substrato probatório. Explico.

O artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Conclui-se, pois, que o ingresso na residência só é possível em caso de flagrante delito, por determinação judicial ou com o consentimento válido do morador. Contudo, nenhuma das hipóteses estava presente no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, julgando o HC n. 598.051/SP, definiu as exigências, para o ingresso policial em domicílio de pessoa suspeita sem mandado judicial, ou seja, para a devida proteção à garantia da inviolabilidade de domicílio, são necessárias providências mínimas.

Para o ingresso na residência em hipótese de flagrante delito, é necessária a

existência de fundadas razões (justa causa) aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

A Corte Federal definiu que o tráfico ilícito de entorpecentes, embora em algumas de suas modalidades seja classificado como crime permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontram as drogas. A entrada somente será permitida em situações de urgências, quando for possível concluir de modo objetivo e concreto que o atraso decorrente da obtenção do mandado judicial possa permitir a destruição ou ocultação da prova do crime ou da própria droga.

Para o ingresso na residência mediante consentimento do morador, é necessário que a autorização seja assinada pelo morador e por testemunhas que atestem que o morador consentiu com o ingresso e que acompanhem a busca realizada, o que deverá ser registrado em auto circunstanciado, em estrita observância ao que determina o art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal, que se aplica a qualquer forma de busca e apreensão domiciliar, com ou sem mandado judicial; ou a diligência deverá ser integralmente registrada em vídeo e áudio, sem cortes ou edição, especialmente se não for possível a assinatura da autorização escrita.

O consentimento para entrada na residência pelo morador deve ser voluntário e livre de qualquer constrangimento ou coação. Vale ressaltar que, havendo dúvida, a prova da existência e validade do consentimento é ônus da prova que recai sobre o Estado, personificado no processo pelo Ministério Público. Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo" (HC n. 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021).

Passando à análise do caso concreto, a ausência de autorização judicial é incontroversa, eis que o competente mandado de busca e apreensão em momento algum foi solicitado.

Também não ficou demonstrado que houve consentimento externado pelo morador.

Segundo os policiais militares condutores, o acusado teria franqueado a entrada deles no interior da sua residência.

Formalmente ouvido, em Delegacia de Polícia e em Juízo, a acusada negou que os fatos tenham se passado dessa maneira, bem como negou que tenha dado autorização para o ingresso policial na residência.

Assim, o suposto consentimento do(s) morador(es) para entrada na residência não foi confirmado de qualquer modo, em Juízo ou fora dele. Julgo crível a história do acusado no sentido de que não conferiu tal autorização, seja porque seria absolutamente inusitado que alguém, sabedor que guarda drogas e arma em sua residência, convidasse policiais militares para uma revista domiciliar.

Ainda que haja elemento de prova em sentido contrário, como o depoimento dos policiais militares, não estão presentes elementos suficientes para convencer o Juízo da validade do consentimento.

Sobre o tema, ensinam os processualistas PIERPAOLO CRUZ BOTTINI e ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO:

Em muitos casos, policiais adentram residências particulares, sem que presentes quaisquer destas situações excepcionais, sob o pretexto de terem obtido o consentimento do morador. (...) Importante analisar a situação do dito 'consentimento' do morador, apto a excepcionar a regra da inviolabilidade do domicílio e autorizar a busca sem mandado judicial. Sabe-se que, nas buscas domiciliares, há um conflito de interesses em jogo a busca da verdade, para realização da justiça criminal, e a preservação da intimidade e da inviolabilidade do domicílio. O consentimento do morador aparece como primeira forma de solução desse conflito. No entanto, é preciso cautela na sua análise, sempre diante das circunstâncias de obtenção da prova e da atuação da autoridade policial. (...) O consentimento, porém, deve ser real e livre, desprovido de vícios como o erro,

violência ou intimidação. Evidentemente que, em cada caso concreto, o consentimento do morador deve ser analisado com cautela e nunca presumido, especialmente para que se evitem abusos da autoridade policial. (...) O TJRS recentemente destacou a invalidade do consentimento de pessoa investigada por tráfico de drogas. Na ocasião, o Desembargador relator pontuou: 'Não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário. Do consentimento a que se refere o art. 5.º, XI, da CF não se infere que poderão ser realizadas buscas sem determinação judicial, apenas sob a anuência do morador. Se assim fosse, veríamos-nos diante de um quadro temerário, no qual os mandados de busca e apreensão seriam dispensáveis, já que polícia sempre poderia conseguir, extrajudicialmente, o 'consentimento' do proprietário. Afinal, é de se ter em conta que, nas circunstâncias descritas nos autos esse aval foi dado sob constrangimento' (Ap 70058172628, Rel. Des. Diógenes V. Hassan Ribeiro, 3.ª Câmara Criminal, DJ 24.06.2014). Dessarte, se há o consentimento do morador para buscas domiciliares, algumas questões devem ser bem refletidas: (I) forma do consentimento; (II) pessoa que consente e seu grau de esclarecimento sobre as implicações da medida. Sobre a forma do consentimento, deve ser expresso e jamais presumido, sendo que não há previsão legal de forma especial. (...). No tocante à pessoa que consente, deve ser aquele titular do direito à inviolabilidade do domicílio. A doutrina destaca que a permissão deve ser do próprio sujeito da medida de busca e apreensão ou de outra pessoa que possa, legitimamente, representá-lo. Ressalvas são feitas, ainda, às habitações coletivas, em que o consentimento por um dos moradores não autoriza a busca na casa ou aposento de terceiros. No entanto, maior relevo tem a questão do grau de esclarecimento do morador que consentiu na realização da busca e apreensão. Para que se solucione o conflito de interesses busca da verdade para realização da justiça e inviolabilidade do domicílio por via consensual, é necessário que aquele que consente tenha pleno conhecimento das circunstâncias e consequências da realização da busca domiciliar, bem como que isso seja documentado. No ponto, não há previsão legal. Contudo, tratando-se de medida que pode implicar a produção de prova contra o próprio morador que consente com a busca, para que ele decida de forma justa e válida se franqueará a entrada em sua residência, necessário que no mínimo lhe sejam esclarecidos seus direitos e o alcance da inviolabilidade do domicílio, bem como as consequências da realização da busca domiciliar. A mesma lógica e o mesmo cuidado são observados nos procedimentos de interrogatórios, tanto judicial quanto policial, a fim de garantir o direito da pessoa de não produzir prova contra si (deriva das previsões constitucionais art. 5.º, LVII e LXII e consagrado do Pacto de São José da Costa Rica, art. 8.º). (...) Além disso, no ponto do consentimento, necessária observância de cuidados, a fim de assegurar que este seja consciente e válido. Frise-se que o consentimento não se presume e requer prova, cujo ônus é do Estado (TRF 2.ª Região, RSE 200551015058355, DJ 22.10.2008). Mais do que isso, parece-nos essencial que sejam esclarecidos, ao sujeito da medida e de forma documentada, os seus direitos, o alcance da inviolabilidade do domicílio e as consequências de sua decisão por franquear a entrada de policiais para a busca domiciliar. Trata-se de medidas mínimas para coibir abusos da autoridade policial e fazer valer um Estado Democrático de Direito" (BOTTINI, Pierpaolo Cruz; DELLOSSO, Ana Fernanda Ayres. O consentimento e a situação de flagrante delito nas buscas domiciliares. Disponível em: [www.ibccrim.org.br/boletim\\_artigo/5199-0-consentimento-e-a-situacao-de-flagrante-delito-nas-buscas-domiciliares](http://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5199-0-consentimento-e-a-situacao-de-flagrante-delito-nas-buscas-domiciliares)>. Acesso em 16 jun. 2016) (grifei).

Tampouco houve visualização de situação de flagrante delito no interior da residência que autorizasse a excepcional entrada no domicílio. A narrativa colhida dos policiais militares deixa claro que, primeiro, houve o ingresso na residência para, depois, ser verificada a situação de flagrante delito, quando só haveria licitude do ingresso no caso contrário, ou seja, se os policiais verificassem que ocorria situação de flagrante delito previamente para só depois ingressarem na residência, amparados pela Constituição Federal, justamente no intuito de fazer cessar a violação à ordem jurídica anteriormente verificada. Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE

USO RESTRITO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). 2. Em nenhum momento, foi explicitado, com dados objetivos do caso, em que consistiria eventual atitude suspeita por parte da acusada, externalizada em atos concretos, tampouco foi feita menção a eventual movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Não há referência a prévia investigação, monitoramento ou campanhas no local. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. Há apenas a descrição de que, quando o recorrido avistou os policiais militares, empreendeu fuga. 3. Uma vez que não há nem sequer como inferir, de fatores outros que não a mera fuga ante a iminente abordagem policial, que o recorrido estivesse praticando delitos de tráfico de drogas, de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da residência onde se homiziou, não há razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, no domicílio da acusada, de drogas e de arma de fogo de uso restrito, sob pena de esvaziar-se essa franquia constitucional da mais alta importância. 4. No caso, houve mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo ora recorrido, o que não configurou, por si só, "fundadas razões" a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial. 5. Recurso especial não provido (STJ - REsp: 1690854 RJ 2017/0208328-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)

Não é possível negar que havia, sim, alguns elementos que pudessem sugerir possível traficância em relação ao acusado, mas tais elementos tinham relevância suficiente apenas para discutir o cabimento de um mandado de busca e apreensão, mas não para o ingresso imediato no domicílio pela polícia.

No caso em concreto, a entrada na residência do acusado se justificou na circunstância que haveria denúncia anônima de traficância no local dos fatos. Tais elementos são demasiadamente frágeis para se autorizar a presunção de situação de flagrante delito na residência do acusado a autorizar o ingresso.

Em relação à denúncia anônima, sabe-se que, em regra, que elas não são suficientes para imediatamente justificar medidas invasivas, mas tão somente para dar início a diligências preliminares de averiguação, tais como campanhas, por exemplo.

O que se observa na jurisprudência do STF e STJ é que a denúncia anônima não deve ser descartada, como se destituída de qualquer valor jurídico. Antes, devem ser realizadas diligências a fim de confirmar a veracidade da notícia. A partir de tal admite-se a instauração de procedimento investigatório e determinação de eventuais medidas invasivas. Isso significa que a utilização de denúncia anônima como elemento desencadeador de procedimentos investigação depende de diligências prévias, inadmitida, portanto, como elemento suficiente à autorização de medida cautelar.

Vejamos, nesse sentido, contundente passagem de voto do Ministro Nefi Cordeiro: "[...] denúncia anônima não é fonte probatória, mas mera informação, passível de gerar movimentação investigatória preliminar, mas jamais fundamento para a restrição a direitos individuais" [STJ:RHC n. 53134/RJ. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe: 26/05/2015]."

Importante notar que inexistia situação de urgência que inviabilizasse a solicitação de mandado de busca e apreensão, de modo que não havia risco na demora de se aguardar o competente mandado, caso deferido.

Em regra, nos crimes de tráfico de drogas não há urgência que impeça o pedido judicial de busca e apreensão, notadamente porque são crimes de perigo abstrato, ou

seja, não há dano nem perigo concreto e imediato de dano a bem jurídico. Tal entendimento é reforçado pela própria circunstância que a Lei n. 11343/06 prevê a possibilidade de retardamento da ação policial na figura do "flagrante diferido", o qual, aliás, somente pode ser realizado com a devida autorização prévia, na linha do que observou o Superior Tribunal de Justiça no HC n. 598051/SP.

Não há elemento dos autos que faça se duvidar da boa-fé dos policiais militares, que certamente buscavam cumprir sua função com a maior eficiência possível, mas tal ânimo e disposição fez com que se excedessem nos limites de suas prerrogativas, o que acaba por contaminar a apreensão realizada nos autos, que lícita seria somente se tivessem levado os fatos apurados ao conhecimento do Poder Judiciário, a fim de que fosse autorizado o ingresso na residência.

Portanto, pelo contexto fático delineado nos autos, não havia elementos concretos que justificassem a invasão de domicílio sem a prévia autorização judicial, valendo destacar, ademais, que não havia urgência que impossibilitasse a solicitação de prévia autorização judicial.

Eis a razão pela qual, dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência do réu, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas.

Além disso, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, "são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras". O dispositivo de lei consagra a teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree ou tainted fruit), desenvolvida pela Suprema Corte Norte Americana, entre as décadas de 1920 e 1930, especialmente no caso *Silverthorne Lumber & Co. v. United States*, de 1920, e caso *Nardone v. United States*, de 1937, que já era adotada pela doutrina nacional e pelo Supremo Tribunal Federal antes da reforma legal. A prova ilícita por derivação é a prova que, conquanto isoladamente considerada possa ser tida como lícita, ela decorre de informações provenientes de prova ilícita. A prova ilícita por derivação sustenta um argumento relacional, ou seja, para se considerar uma determinada prova como fruto de uma árvore envenenada, deve-se estabelecer uma conexão entre ambos os extremos da cadeia lógica; dessa forma, deve-se esclarecer quando a primeira ilegalidade é condição sine qua non e motor da obtenção posterior das provas derivadas, que não teriam sido obtidas não fosse a existência da referida ilegalidade originária. Estabelecida a relação, pronuncia-se a ilegalidade. Assim, sendo, são também nulas as provas que derivaram deste primeiro ato de apreensão, resultando no esvaziamento probatório dos autos, a resultar na ausência da materialidade do delito.

Neste contexto, só se pode lamentar que, havendo indícios suficientes para deflagrar uma investigação robusta com a finalidade de interromper a circulação de drogas na região e prender agente da mercancia ilícita, a punição dos culpados seja colocada em risco pela inobservância do devido processo legal. Tais restrições ao desempenho da atividade persecutória concorde-se ou não; constituam ou não empecilho para a rápida repressão de atividades ilícitas são constitucionalmente asseguradas, de modo que a sua observância é obrigatória.

Assim, por não remanescerem provas lícitas a respeito da conduta da acusada, de rigor a sua absolvição.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o acusado ROBSON ALVES da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003).

Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Custas nos termos da lei.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida e da arma, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e após, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I.

São Paulo, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA